

1500394-97.2019.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: THAÍS DA SILVA PORTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... na inicial pela ré no tocante ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS - Absolvição por ausência de culpabilidade diante da coação moral irresistível. Ausência de provas quanto à justificativa de grave ameaça aos réus por ter o réu contraído dívidas no presídio. Crime impossível - afastado. Havendo possibilidade da entrada da droga na penitenciária ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandópolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500394-97.2019.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500394-97.2019.8.26.0605

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2372223/2019 - DEL.POL.LAVINIA, 9261192 - DEL.POL.LAVINIA, 1784/19/106 - DEL.POL.LAVINIA, 2372223 - DEL.POL.LAVINIA, 1784/19/106 - DEL.POL.LAVINIA, 2372223 - DEL.POL.LAVINIA, 1784/19/106 - DEL.POL.LAVINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLEN CRISTINA DE SOUZA LIMA DONA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAÍS DA SILVA PORTO

Vistos.

KELLEN CRISTINA DE SOUZA LIMA DONA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois no dia 29 de dezembro de 2019, por volta das 10h52, na penitenciária III, localizada na Vicinal Manoel Caetano, Centro, na cidade de Lavínia, nesta Comarca de Mirandópolis, supostamente trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 108 (cento e oito) invólucro de maconha, com peso aproximado de 49 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08, auto de constatação preliminar de fls. 09/10 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 39/42, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou na exordial acusatória, a denunciada ocultou os entorpecentes no interior de azeitonas e em uma vasilha contendo macarrão e dirigiu-se ao referido estabelecimento prisional para visitar seu companheiro, custodiado no local. Ocorre que, durante procedimento de revista nos mantimentos trazidos pela denunciada, policiais penais encontraram e apreenderam a referida substância entorpecente, além de 07 papéis que pensaram tratar-se de substância sintética. Em sede policial, a denunciada alegou que seu companheiro pediu que ela pegasse o alimento em uma pousada.

Tendo em vista a natureza e a quantidade da substância encontrada, sua forma de acondicionamento, bem como as circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam efetivamente ao consumo de terceiros.

A acusada foi presa em flagrante delito no dia 29 de dezembro de 2019 (fls. 01/02) e, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares (fls. 31/33).

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2022 (fls. 117/118). A ré foi notificada (fl. 102) e apresentou defesa prévia (fls. 109/113). Folha de Antecedentes (fls. 73/75) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais não contendo outros registros (fls. 78/79).

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 02 de junho de 2022 (fls. 165/166). Realizou-se a oitiva da testemunha Marcio Rogério Nespoli (fl. 164). Foi decretada revelia da ré, pois mudou de endereço sem comunicar este Juízo. Tendo em vista que a acusação insistiu na oitiva da testemunha ausente Celso Francisco Lopes, a audiência foi redesignada para a sua oitiva, determinando a expedição de mandado com condução coercitiva. Em audiência em continuação no dia 04 de outubro de 2022, realizou-se a oitiva da testemunha Celso Francisco Lopes (fl. 246).

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação da ré nos termos da denúncia; e, a Defesa técnica, por seu turno, alegou atipicidade da conduta, uma vez que portar a pequena quantidade de 49g de maconha pode configurar qualquer outra conduta, menos a de tráfico de drogas. Sustentou que restou comprovada a ineficácia absoluta do meio, uma vez que é sabido de todos que para adentar em uma unidade prisional, minuciosas inspeções são feitas. Em conjunto, alega que não fora a ré flagrada entregando, vendendo, repassando ou qualquer conduta prevista na legislação como tráfico de drogas, sendo nítida a intenção de consumo próprio. Pugnou pela absolvição da ré, ou ainda, em caso de condenação, que haja a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.434/06 e a aplicação do previsto no artigo 33, §4º do mesmo diploma, bem como a condenação seja dada nos mínimos parâmetros legais.

É o relatório.

Passo a fundamentar:

A presente ação penal merece prosperar.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica descrita na denúncia. A materialidade delitiva é indubitosa e restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão de fl. 08 e pelo exame químico-toxicológico (fls. 39/42), concluindo-se que o material examinado, trata-se de Tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis Sativa, L (MACONHA), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais no sentido de lhe apontar como sendo a autora do crime em apreço.

Vejamos.

Foram produzidas provas na fase inquisitorial.

A testemunha CELSO FRANCISCO LOPES (fl. 03), agente penitenciário, afirmou que é policial penitenciário, trabalha na penitenciária III de Lavínia, e que ao revistar o "jumbo" trazido por Kellen Cristina de Souza Lima Dona, que iria visitar o detento Tiago Ariano de Souza Dona, acabou encontrando (ocultados em papéis de cigarro) sete pedaços de papéis, possivelmente droga sintética conhecida por 4K, e no interior de azeitonas, que estavam em uma vasilha contendo macarrão cento e oito porções de maconha. Diante dos fatos conduziu a visitante até o plantão policial.

MARCIO ROGERIO NESPOLI (fl. 04), agente penitenciário, afirmou que é policial penitenciário, trabalha na penitenciária III de Lavínia, e que prestava serviços no setor de revista de "visitantes", juntamente com seu colega Celso Francisco, e ao revistarem o "jumbo" trazido por Kellen Cristina de Souza Lima Dona, que iria visitar o detento Tiago Ariano de Souza Dona, acabaram encontrando (ocultados em papéis de cigarro) sete pedaços de papéis, possivelmente droga sintética conhecida por 4K, e no interior de azeitonas, que estavam em uma vasilha contendo macarrão cento e oito porções de maconha. Diante dos fatos conduziram a visitante até o plantão policial.

A ré KELLEN CRISTINA DE SOUZA LIMA DONA (fl 05), afirmou que é moradora da cidade de Birigui/SP e estava na cidade de Lavínia/SP para visitar seu companheiro, o custodiado Tiago Ariano Souza e Silva, o qual se encontra recluso na penitenciária III da cidade. Relatou que o visitava acerca de um ano e meio. Sobre os fatos, relatou que havia pego uma "cumbuca" de comida em uma pensão em Lavínia/SP, a qual não soube informar qual era e que não tinha noção de que pudesse haver entorpecente nos alimentos. Ressaltou que costumava fazer os alimentos que levava ao presídio. Relatou que seu companheiro quem indicou tal pensão e que insistiu que ela pegasse os alimentos em tal pousada. Não conhece nada na cidade de Lavínia, por isso não sabe o local exato onde pegara os alimentos. Indagada se possuía advogado constituído disse que não e que manifestava desejo em ser assistida pela Defensoria Pública. Sobre a comunicação de sua prisão, entrou em contato com seu genitor, o qual ficou ciente da prisão. Relatou que possui três filhos menores de idade. Indagada se já fora presa anteriormente, disse que não.

A prova foi repetida em fase judicial.

A testemunha CELSO FRANCISCO LOPES (fl. 246), agente penitenciário, relatou que durante a revista da alimentação e de alguns pertences que a visitante estaria trazendo para o interior da unidade prisional para o preso durante a visita, a testemunha encontrou dentro de alguns envelopes de papel de cigarro pedaços de papéis que no momento lhe causou suspeita do entorpecente conhecido como k-4, momento em que conduziram a visitante até a portaria para fazer o comunicado a respeito desses papéis e neste mesmo momento também resolveram verificar também as vasilhas com alimentação desta visitante, e nesta foi encontrado dentro de azeitonas sem caroços, no interior delas pequenos volumes de material esverdeado com cheiro de entorpecente. Disse que não se recorda da quantidade de entorpecente, mas afirmou que era uma quantidade bem grande, que havia diversas porções dentro das azeitonas.

MARCIO ROGERIO NESPOLI (fl. 164), agente penitenciário, declarou que no dia dos fatos, seu colega Celso prestava serviços junto à revista de pertence de visitantes. Logo no início da revista nos pertences da Sra. Kellen, foram encontrados pedaços de papéis que aparentavam ser a droga K4 dentro do pacote de papéis de cigarros. Nesse momento, pararam a revista, a visitante foi retirada do convívio das demais e levada à portaria para os procedimentos de praxe. O declarante estava acompanhando seu colega juntamente com a acusada. Ao terminarem a revista no resto dos pertences trazidos por esta visitante, encontraram mais de cem papelotinhos aparentando ser maconha dentro de azeitonas em uma vasilha com macarrão. Ao ser questionada, a visitante afirmou que pegou a vasilha de outra pessoa fora do presídio e não tinha conhecimento do que estava dentro do macarrão.

A ré KELLEN CRISTINA DE SOUZA LIMA DONA é revel.

Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram amplamente comprovados pelos elementos colhidos.

As provas dos autos são robustas e convincentes quanto ao delito de tráfico de drogas, não havendo como se sustentar as teses da Defesa técnica da ré, pleiteando sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, bem como a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, visto que o conjunto probatório aponta de forma inequívoca para prática da conduta descrita na inicial pela ré no tocante ao crime de tráfico de drogas. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição por ausência de culpabilidade diante da coação moral irresistível. Ausência de provas quanto à justificativa de grave ameaça aos réus por ter o réu contraído dívidas no presídio. Crime impossível – afastado. Havendo possibilidade da entrada da droga na penitenciária pelo meio escolhido o crime permanece ativo. Prova indireta que pelas circunstâncias, local do crime (penitenciária) e quantidade de droga evidenciam o crime. CONDENAÇÃO do corréu. Afastado. Ausência de provas que o corréu tivesse ciência da conduta da ré. Causa de aumento da pena. Mantida. Certeza quanto ao cometimento do crime no interior do estabelecimento prisional. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500762-75.2019.8.26.0583; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020) (Grifo nosso).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos das agentes penitenciárias em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada – Apreensão de razoável quantidade de droga (01 invólucro contendo cocaína, com peso de 137,3 gramas) – Desclassificação para uso próprio. Descabimento – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas demonstrada (crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional) – Reconhecimento das excludentes de punibilidade do erro de tipo ou do erro de proibição. Inviabilidade – Crime impossível. Inocorrência – Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Elevação mitigada ao coeficiente de 1/6 – Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Prisão domiciliar. Competência do Juízo da Execução – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Apelo provido em parte para reduzir as penas. (TJSP; Apelação Criminal 0000025-59.2018.8.26.0591; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pacaembu - 2º Vara; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019) (Grifo nosso).

Além disso, a própria ré, em sede extrajudicial afirmou que visitava o detento Tiago Ariano de Souza Dona a cerca de um ano e meio, portanto era sabedora de todas as regras pertinentes às revistas a que são submetidas para realizar a visita ao sentenciado recluso. Assim, não é crível que tenha se submetido a pegar uma vasilha de alimentação em um local desconhecido, sabendo que esta seria inspecionada durante a revista para ingresso no estabelecimento prisional, razão pela qual não há que se falar em erro de tipo, visto que tinha discernimento de que o seu comportamento adotado no dia dos fatos não era compatível com os procedimentos de ingresso na unidade prisional.

Por fim, a prova oral coligida em juízo é inconteste.

As testemunhas ouvidas declararam de forma firme e uníssona o desenvolvimento dos

fatos. Trouxeram detalhes da conduta da acusada, não deixando dúvidas sobre a materialidade e autoria delitivas. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Também:

"(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos" (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 659.024/SP, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021).

No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os agentes de segurança penitenciárias teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente a ré.

Portanto, nada há nos autos para conferir suporte ao seu pleito defensivo. Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação da ré medida que se impõe.

Passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal. No que tange à dosimetria da reprimenda, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis à acusada (folha de antecedentes de fls. 27/28 e Certidão de fl. 26), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa..

Na terceira fase, promovo o aumento de 1/6, pelo reconhecimento da causa ingresso em estabelecimento prisional nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, totalizando a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O incremento se dá no patamar mínimo porque o produto espúrio não atingiu a efetivamente população carcerária, o que minora o desvalor da conduta.

Por fim, aplicável redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que a ré é primária, portadora de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa, razão pela qual a pena deverá ser reduzida de 2/3, ou seja, 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Assim, tem-se por final a pena de 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime ABERTO, a teor do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Ademais, considerando que a ré preenche os requisitos previstos no artigo 44 do

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por 02 (duas) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista. Em caso de descumprimento, a ré descontará a sanção no regime já determinado.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica da ré.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR KELLEN CRISTINA DE SOUZA LIMA DONA, devidamente qualificada, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pelo valor mínimo, por infração ao artigo 33, caput, c.c. art. 40, III da Lei nº 11.343/06, em regime inicial ABERTO, SUBSTITUÍDA por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na Prestação Pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser determinada sua destinação pelo Juízo da Execução, na razão do artigo 45, §1º do Código Penal, e Limitação de Fim de Semana, nos termos do artigo 48 do Código Penal, por prazo igual a pena privativa de liberdade acima prevista, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu solta a este processo e não há alteração fática que recomende a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Determino a destruição da droga apreendida, guardando-se quantidade suficiente para contraprova. Oficie-se. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Condeno a ré a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o cadastro da condenação em sistema próprio. Providencie-se, também, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Com trânsito em julgado, intime-se a ré para o pagamento da multa penal no prazo de 10 (dez) dias, e expeça-se certidão ao patrono dativo, pelo máximo da tabela do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP, se o caso.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

P.I.C.

Oportunamente, archive-se o feito.

Mirandópolis, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA